



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 189/06

בענין :

1. סטר דניאל ורות
 2. אסס בתיה
 3. סטר אויגן
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד ע. אטיאס ואח'
רח' חורי 2 ת"ד 4133 – חיפה

התובעים

נ ג ד

בר עוז ששון וגלית
ע"י ב"כ עו"ד שלמה בר עוז
רח' הנמל 2- חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

עובדות

1. עסקינן בבית משותף שנמצא בשד' קיש 22 חיפה ומזוהה כחלקה 261 בגוש שומה 10809. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ולפי פרטי הרישום הוא מונה 4 דירות: שתי דירות בקומת קרקע ושתי דירות בקומה א', היא הדירה העליונה. על הבית מחפה גג רעפים. צו הרישום מפרט צמידויות שונות, לרבות צמידות של גג הבית ליחידת משנה 4.
2. התובעים כולם הם בעלי יחידות המשנה 1-3 והנתבעים הם בעלי יחידת משנה 4.
3. בכתב התביעה עותרים התובעים לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים להרחיב דירתם אל תוך חלל הגג המצוי מעל הדירות העליונות והצמוד לדירתם כאמור לעיל.

4. עילת התביעה היא היתר בניה שקיבלו הנתבעים, לבקשתם, מרשויות התכנון לאישור תוספת בניה לדירתם המרחיבה דירתם אל חלל הגג של הבית. התובעים טוענים כי לדירת הנתבעים הוצמד אמנם גג הבית, אולם לא הוקנו לה זכויות בניה, ולפיכך הן מהוות רכוש משותף לכלל הדיירים. כמו כן לנתבעים לא עומד הרוב הדרוש לפי חוק להרחבת דירתם. בהעדר הסכמה ברוב בעלי הדירות שנקבע בסעיף 71' לחוק המקרקעין, מנועים הנתבעים מליישם את היתר הבניה שקיבלו. התובעים ביחד מהווים כדי למעלה מ-70% מבעלי הדירות בבית, ובהיותם מתנגדים, ממילא לא עומד לנתבעים הרוב הדרוש לשם הבניה. עוד נטען כי הבניה המבוקשת תפגע בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף כפי שהיתה בעת גמר הבניה ותגרום לתובעים למטרד ולרעש. התובעים עומדים על זכותם להתנגד עקרונית לכל בניה בין אם יפגעו זכויות הבניה שלהם בין אם לאו. לאור האמור מבוקש למנוע בניה זו.

5. להגנתם, טוענים הנתבעים כי התביעה הוגשה בשיהוי שכן עפ"י החלטת הועדה מיום 26/06/06 הושעתה הוצאת ההיתר למשך 30 יום על מנת לאפשר לתובעים לערור לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה והתובעים לא רק שלא עשו כן אלא גם תביעתם לבית המשפט הוגשה רק ביום 19/09/06. כן נטען כי התובעים מיצו את זכות ההתנגדות בוועדה המקומית, וזו - לאחר שבחנה טענותיהם תוך שקילת השיקולים הקנייניים והתכנוניים דחתה את ההתנגדות והחליטה לאפשר הבניה.

6. עוד טוענים הנתבעים כי רכשו דירתם כשלזו צמוד גג וברי כי משמעות הצמדה זו הינה הכוונה שהם יוכלו לממש הצמדתם זו ע"י הרחבת דירתם על גג זה, שאם לא כן הינך מרוקן מתוכן ומשמעות הצמדה זו. לאור האמור, שקילת האינטרסים ההדדיים מחייבת העדפת אלו של הנתבעים ודחיית התביעה.

7. מטעם התובעים העידה תובעת מספר 2 ומטעם הנתבעים העיד נתבע מספר 1, איש איש כנטען בכתבי טענותיו, ולא עלו טענות שזיכרון לא בא בכתבי הטענות. הוגש גם כראיה היתר הבניה שניתן לנתבעים אשר מדגים את הבניה המתוכננת.

8. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה. בסיכומי-הטענות חזרו הצדדים על עיקרי עמדותיהם כפי שבאו בכתבי הטענות לאמור:

(א) התובעים מזה הדגישו את היעדר ההסכמה של בעלי דירות ברוב המהווה תנאי בלתו אין לאישור הבניה, ואת העובדה שעפ"י הפסיקה הצמדת גג אינה מקנה באופן אוטומטי את הזכות לבנות, אלא את זכות השימוש באותו החלק בלבד. שימוש באחוזי הבניה מחייב הסכמת בעלי הדירות כהוראת סעיף 71 ב' לחוק המקרקעין.

(ב) הנתבעים מזה הדגישו את העובדה כי נדחו התנגדויות התובעים בוועדה המקומית, ללמדך שנמצא שהבניה אינה פוגעת בתובעים, וכן את העובדה כי עפ"י תנאי ההיתר אושרה להם הבניה באופן שהינם עושים שימוש בחלקם היחסי באחוזי הבניה של הבית ולא מעבר לכך. ומקום שקיימים אחוזי בניה לניצול וכן הצמדת גג, הרי שעקרון תום הלב מחייב כי השימוש בזכות ההתנגדות לבניה של התובעים ייעשה בתום לב וכי תאושר להם הבניה, במיוחד מקום שלא הוכחה פגיעה כלשהיא בתובעים. הנתבעים הפנו אותי אל פסיקה שקובעת כי זכויות הבניה אינן מחלקיו הפיזיים של הבית המשותף ואינן בגדר רכוש משותף ועל כן

אין להחיל סעיף 71 ב לחוק המקרקעין על נסיבות מקרה זה. {ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר תק-על 2005(1)}. אליבא דידם של הנתבעים אותה פסיקה אליה מפנים התובעים שקובעת הפרדה בין הצמדה לבין זכויות הבניה נכונה כאשר מדובר בניצול של זכויות בניה בלתי מנוצלות של דייר על חשבון דייר אחר אך אינה רלוונטית מקום שדייר מבקש לבנות כדי חלקו היחסי בלבד בזכויות הבניה ולא למעלה מכך. הנתבעים דרים בצפיפות בדירה בת שלושה חדרים מקום שבנקל יכולים להרחיב דירתם ולהקל על מצוקתם ללא כל פגיעה במי מדיירי הבית.

המסגרת הנורמטיבית

9. הוראות הדין בגידון מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין (שהוכנסו לחוק במסגרת תיקון 18 לו). בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". סעיף 71ב(א) מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים: החלטה של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות וכן של מי ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

10. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף. יוצא מכאן כי אם הנתבעים יטענו שזכותם אינה נטועה בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין אזי נחוצה להם הסכמה של כל בעלי הדירות למימוש היתר הבניה שקבלו.

11. קנין הוכר בדין כזכות יסוד הראויה להגנה. דיני הקנין של המשפט הפרטי, ובמקרה הזה חוק המקרקעין, הם שקובעים את הקריטריונים להגנה על זכות זו. ראה ברק, פרשנות במשפט, כרך ג', עמ' 786 ואילך. בתיקון 18 לחוק המקרקעין נקבעה מערכת של איזונים מהותיים אשר נועדה להקטין את הפגיעה בקנין שנגרמת בעטייה של בניה ברכוש המשותף. המלומד דויטש בספרו קנין, כרך א', עמ' 701 בוחן אחת לאחת אם תנאי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נשמרים בתיקון 18 לחוק המקרקעין ומוצא כי התיקון הוא תקף. בע"א (חי') 1725/05 דוד נ' נברוצקי (השופטים גריל חופרי ופינקלשטיין) פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' "

סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 3589(1)2005. תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג' לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

12. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה קיימת אגב מימוש זכויות בניה מצריכה הסכמה למצער של שלוש רבעים מבעלי הדירות. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת.

13. דינן, אפיונן ומעמדם של זכויות בניה נדונו בהרחבה בע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר תק-על 2005(1) אליו מפנים הנתבעים. כב' הנשיא דאז שמגר בע"א 432/83 שאול מזרחי נ' מרדכי חביב, פ"ד מ(4) 673, איפיון את זכויות הבניה באופן הבא:

"זכויות הבניה הינן נכס שהינו בבעלות משותפת, אף על פי שאינו חלק מן הרכוש המשותף. הזכויות הללו נובעות מהבעלות בקרקע, וכיון שהקרקע עליה ניצב בית משותף שייכת במשותף לדיירים, אף זכויות הבניה עליה שייכות להם במשותף. אולם בעלים במשותף של זכויות בניה יכול לוותר עליה, ולהעבירה לאחר".

כב' השופט טירקל זיהה אותן בפסק דין שטרייכר הנ"ל באופן הבא:

"ניתן, אפוא, לומר כי אכן זכויות הבניה אינן בגדר "רכוש משותף", כהגדרתו בחוק המקרקעין, אלא הן זכויות בבעלות משותפת של בעלי הדירות. על כך אמרתי במקום אחר: "כי עם רישום הבנין כבית משותף, אין זכויות הבניה 'נמוגות' אלא הן מוסיפות להתקיים בבעלותם המשותפת של כל בעלי הדירות בבית".

14. אף זאת על פי הפסיקה, הוצאת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה פלונית מעבירה את אותו החלק לבעלותו של אותו בעל דירה. הוא רשאי לנהוג בה מנהג בעלים כגון על ידי איסור על אחרים להשתמש באותו החלק, הגם שמלכתחילה אותו החלק היה רכוש משותף. ואולם, לעצם הצמדה של חלק מסוים כגון גג לא נלווית הזכות לבנות עליו תוך מימוש זכויות בניה. בע"א יוסף ואח' נ' בכר פ"ד לב (3) 617 נאמר:

"אין ספק שעצם הצמדת הגג ליחידה מסוימת איננה נותנת לבעל היחידה זכות לבנות על הגג כעולה על רוחו ללא הסכמת בעלי הדירות האחרות בבית, אלא גורמת אך ורק לכך שאותו חלק מהגג חדל להיות חלק מהרכוש המשותף והופך להיות חלק מהדירה."

וכן בע"א שואעי נ' בכרך ואח' פ"ד נג (1) 469 נקבע:

"ככלל יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבניה בבית-משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל-דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות."

דין

15. לנוכח הוראות הדין שנסקרו לעיל לא העמידו הנתבעים הגנה ראויה, ודין התביעה להתקבל. אלה נימוקי החלטתי:

(א) הוכח, ועצם הגשת התביעה על ידי שלושה מתוך ארבעה בעלי הדירות בבית המשותף מדברת בעד עצמה, שרוב בעלי הדירות **מסרבים** לבניה המתוכננת.

(ב) סעיף 71 ב' לחוק המקרקעין חל הן על הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה לשם בניה (מה שאינו נחוץ כאן לפי שלנתבעים קיימת הצמדת הגג), והן בחלוקת זכויות הבניה הנדרשות לשם הבניה. לא מצאתי תימוכין בחוק או בפסיקה לפרשנות המוצעת ע"י הנתבעים לפיה מקום שנעשה שימוש ע"י דייר כדי חלקו בזכויות הבניה ותו לא, לא נדרשת הסכמת יתר דיירי הבית, בהבדל ממקום בו מבקש דייר לעשות שימוש בזכויות בניה יתרות על חלקו היחסי בזכויות הבניה שם כן ימצא בגדר תנאי סעיף 71ב' לחוק.

(ג) משלא נתמלאו תנאי הסף של סעיף 71ב' (א) לחוק המקרקעין נסתם הגולל על זכות הנתבעים לממש את היתר הבניה.

(ד) הטענות בדבר שיהוי שהועלו בכתב ההגנה נזנחו בהמשך וטוב עשו הנתבעים שלא חזרו להעלותם, שכן כפי שכבר נפסק רבות יש להבחין בין ההליך התכנוני המתנהל בועדות הרישוי ובמסגרתו נשקלים שיקולי תכנון כהוראת דיני התכנון, לבין ההליך הקנייני המתנהל בין בעלי הזכויות

במקרקעין. יתרה מכך, לשכת המפקח על רשום המקרקעין אינה מהווה ערכאת הערר על החלטות הועדות ואינה גם כפופה למועדים אותם קוצבת הוועדה לצורך הוצאת היתר הבניה. המועדים אותם קצבה הועדה המקומית לשם הגשת ערר אף הם תואמים את דיני התכנון, ואינם המועדים המחייבים בעת הגשת תביעה בפני המפקח על רשום מקרקעין.

(ה) ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר אליו מפנים הנתבעים אינו יכול להושיעם שכן שם הוכח עובדתית כי בחוזי הרכישה של דירות הבית נרכשו במפורש גם זכויות הבניה היחסיות.

(ו) אינני מקבלת את טענת הנתבעים כאילו אין בבניה המתוכננת כדי לפגוע במי מהתובעים. אמנם בניה כאמור היתה מצמיחה תובעים יתרון בלבוש היעדר הצורך בהסכמת הנתבעים להרחבת דירותיהם שלהם, יתרון שמוסדר בסעיף 71' לחוק המקרקעין. אך מנגד על פי תשריט היתר הבניה צפויה להתבצע על הגג בניה המחפה על דירת התובעת 3. גם המראה הארכיטקטוני של הבית צפוי להשתנות בשלוש מחזיתות הבית באופן שמגג רעפים שלם יישאר גג רעפים חלקי במקום שיוותר לאחר הבניה.

(ז) לתובעים קנויה הזכות להתנגד לבניה ואף ללא כל צורך לנמק התנגדותם זו. הפרק הרלוונטי של חוק המקרקעין לא הסמיך את המפקח על רישום מקרקעין לבחון את מידת הסבירות או תום-הלב העומדים ביסוד עמדת התובעים. בע"א (י-ם) 4049/98 דנה כבוד השופטת אור בסירוב בעלי דירות להקמת מעלית בבית משותף. הדברים העקרוניים שקבעה שם יפים גם לכאן לאמור:

"אילו סבר המחוקק שיש לחייב או לאפשר התקנת מעלית בבית משותף גם ללא הסכמת רוב של 2/3 מבעלי הדירות, אם המתנגדים להתקנתה – מתנגדים ממניעים פסולים ואחרים, או ללא נימוק סביר – מן הסתם היה טורח לציין זאת במפורש. משנמנע המחוקק מעשות כן – די לבעלי רוב הדירות לומר שהם מתנגדים להתקנת מעלית אף מבלי ליתן טעם כלשהו או אפילו מתוך רשעות לשמה – ואין דרך חוקית לחייבם לעשות כן". (תק-מח 98(1)1885). מקום שהמחוקק הסמיך את המפקח על רישום מקרקעין לבחון את סבירות ההתנגדות של בעל דירה הוא קבע כך מפורשות. ראה סעיף 59ג(ד) לחוק המקרקעין. ראה גם איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, (חלק שלישי) עמ' 233."

16. הנתבעים מעלים כטענה את מצוקת המגורים של משפחתם. עם כל ההבנה לטענה זו, החוק אינו מכיר בה כמקנה זכות; מכל מקום לא הופנית להוראת דין לפיה יש לי הסמכות לשקול שיקולים סוציו-אקונומיים.

17. משכך, משהוכיחו התובעים את זכותם למנוע בעד הנתבעים מימוש היתר הבניה, ומנגד הנתבעים לא הוכיחו כי יש להם הזכות לבנות על הגג המוצמד לדירתם על פי היתר הבניה חרף היעדר ההסכמה של יתר בעלי הדירות אני מקבלת את התביעה.

18. ניתן בזה צו האוסר על הנתבעים או מי מטעמם לבצע כל בניה מכל סוג שהוא על גג דירתם בבית המשותף הנדון.

19. אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובעים יחד, באמצעות בא כוחם, הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (19.09.06) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' יב' בשבט התשס"ז (31.01.07)
העתיקים ישלחו לבאי כוח הצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת על רישום מקרקעין